

1500332-41.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... de Registro: 01/08/2022)

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Sentença procedente. Recurso ministerial. Pleito de condenação pela associação para o tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares: 1.1. Inépcia da denúncia. 1.2. Ilícitude probatória: a) ilicitude da busca pessoal; b) realização de atividade investigativa pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500332-41.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500332-41.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033409/2022 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22836997 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 412/22/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2033409 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO EDUARDO BARBOSA MOURAO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

Eduardo Felipe Almeida Santos Silva e Fabio Eduardo Barbosa Mourão foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, pois, segundo denúncia (fls. 106/107), no dia 04/02/2022, por volta das 11h15min, na Estrada da Boiada, nº 6550, Sítio Borda da Mata, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, traziam consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, 15,91g de cocaína em forma de "crack", fracionada em 83 unidades, 40,8g de cocaína, dividida em 36 tubos plásticos, e 222,14g de tetrahydrocannabinol, acondicionado em 79 porções, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 07), laudo definitivo (fls. 138/140), o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02/03/2022 (fl. 108).

Promovida a citação (fls. 173/174), os réus apresentaram resposta à acusação (fls.

151/157 e 161/167).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 170 e 242), na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório.

Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais apresentadas oralmente em audiência.

É o relatório.

Passo a decidir.

Conforme já deciso em audiência, não há qualquer nulidade na entrevista realizada pelo advogado de Fábio Eduardo com a presença da escolta policial.

Nos dias de hoje, é tranquila a jurisprudência, inclusive do Col. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se não vier demonstrado o prejuízo para a Defesa do réu.

Confira-se:

"A Suprema Corte tem afirmado que "o princípio do *pas de nullité sans grief* exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção" (HC nº 98.434/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/9/14). 8. Embargos rejeitados." (RHC 122174 AgR-ED, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, Processo Eletrônico DJe-229 divulg 20-11-2014 public 21-11-2014).

Vale dizer, para que a alegação trazida pelo defensor tivesse o condão de anular a audiência realizada em razão do advogado não ter se entrevistado "reservadamente" com seu cliente, seria imprescindível que ele indicasse, de forma concreta, em que ponto essa privação impediu que orientasse o réu, ou mesmo explicasse a ele os fatos e as consequências de seu interrogatório.

No caso dos autos, o que se percebe é que o advogado teve plenas condições de manter contato com o seu cliente, sendo que a escolta indicou que não haveria possibilidade de permanecer sozinho em sala, eis que o advogado estava remotamente e não poderia estar em eventual sala de entrevista com o preso. A sala de audiências é contígua com o gabinete e possui duas outras portas de saída, sendo que não seria possível evitar eventual fuga ou ação do preso contra a minha pessoa sem que a escolta atuasse de maneira rápida a garantir a segurança do ato.

Ora, é natural que em um Fórum do interior do Estado de São Paulo (com dimensões acanhadas e muitas vezes antigas), as instalações não sejam as absolutamente adequadas para a entrevista reservada do advogado com o preso, mas isso, por si só, não indica que sendo assegurado o acesso do profissional ao cliente antes da audiência exista constrangimento ilegal. Os guardas da escola em nada influenciam no relato ou na conversa com o advogado.

A presença da escolta visa somente assegurar a segurança não só do preso, mas também das pessoas que estão no prédio, de forma que, ainda que o advogado não tenha conseguido ficar sozinho com o réu, o certo é que teve assegurado o direito de conversar com ele antes do interrogatório, que é suficiente para a regularidade do ato processual impugnado.

Finalmente, não é demais lembrar, trata-se de advogado constituído de sorte que certamente teve condições de manter contato com o réu anteriormente e, nessa ocasião, explicar a ele sobre a imputação e os detalhes da audiência de instrução, de sorte que, também por isso, não há prejuízo a ser percebido. Tanto é assim, que já se decidiu pela inexistência da nulidade em casos semelhantes:

"...A possibilidade de entrevista reservada do réu com seu Defensor antes do interrogatório, introduzida pela Lei 10.792/03, buscou resguardar ao acusado, desprovido de Advogado constituído, o direito de receber orientações de um Defensor Público ou Dativo, destinatários prioritários da norma, nomeado para o ato; na verdade, o Advogado constituído já terá tido a oportunidade de conversar com seu cliente, orientando-o das consequências de suas declarações em juízo e da linha de defesa a ser adotada. 2. O fato de os Policiais que participavam da sua escolta permanecerem no recinto em que se deu a entrevista reservada, a fim de garantir a

segurança do local e das pessoas que ali circulam, exigida para o caso, não ofende a ampla defesa e o contraditório. 3. Ademais, eventual alegação de inobservância ao art. 185, § 2o. do CPP, quando o réu já é assistido por Advogado constituído, representa nulidade relativa, de sorte que depende de comprovação concreta do prejuízo sofrido. Precedente do STF. 4. A argumentação de nulidade diante da realização da audiência de interrogatório de co-réus na mesma data e horário impossibilitando a participação do seu Advogado não deve ser conhecida, uma vez que o impetrante não traz aos autos qualquer prova do alegado. 5. Mantidos incólumes os atos processuais, cuja validade era questionada, resta prejudicado o exame do alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução. 6. Habeas Corpus denegado, em conformidade com o parecer ministerial." (HC 152.060/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho, Quinta Turma julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010). "...DIREITO DE O RÉU SE ENTREVISTAR RESERVADAMENTE COM SEU DEFENSOR. OBSERVÂNCIA PELA TOGADA DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA ESCOLTA NO RECINTO. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL E DO PRÓPRIO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO PACIENTE. EIVA INEXISTENTE. 1. De acordo com o termo de interrogatório, ao paciente foi assegurado o direito de se entrevistar reservadamente com seu advogado, tendo a escolta sido mantida no recinto para garantir a segurança daqueles que estavam presentes no local, medida que não impediu que exercesse a sua ampla defesa, tampouco lhe causou prejuízos, o que impede o reconhecimento da eiva articulada na impetração. Precedente. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 349.059/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016). Habeas corpus - Advogado constituído - Conversa reservada com o preso antes da audiência - Entrevista autorizada e assegurada pela Magistrada - Presença da escolta no momento - Irrelevância - Fórum de Comarca do interior do Estado de São Paulo - Falta de local para entrevista individual - Profissional contratado que, por certo, teve condições de conversar com o preso antes da audiência - Prejuízo não demonstrado - Constrangimento ilegal - Inexistência - Ordem denegada (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2096725-27.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/07/2017; Data de Registro: 14/07/2017)

Igualmente, não há que se falar em irregularidade da atuação dos guardas municipais.

Como sabido, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Nesta categoria de infrações, o sujeito pratica uma violação da norma penal que se prolonga no tempo. Estará, portanto, em constante estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa (art. 303 do CPP).

O Código de Processo Penal, em seu art. 301, permite que qualquer pessoa do povo efetue prisão de quem se acha em flagrância delitiva. É cediço que o art. 144, §8º, da Constituição Federal determina que a Guarda Municipal será destinada à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo, portanto, como principal função a de assegurar a segurança pública, tampouco investigar a prática de crimes. Nada obstante, a referida disposição não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante aquele que estiver cometendo um delito. Tal entendimento não discrepa da posição consolidada pelos Tribunais Superiores:

"Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato da prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda Municipal não revela ilegalidade" (STJ, HC nº 394.112/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 03/08/2017)

No mais, merece destaque que, pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, que disciplina o referido art. 144, §8º, da Constituição, é competência específica das guardas municipais colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social (art. 5º, IV), bem como encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração penal (art. 5º, XIV).

Neste caso, os guardas, em patrulhamento de rotina, presenciaram a atitude suspeita dos réus, os quais empreenderam em fuga quando da aproximação da viatura. Assim,

era presumível que eles pudessem estar cometendo um delito, não tendo sido a ação dos guardas decorrente de qualquer investigação prévia, sendo evidente que a atitude dos réus não é a que se espera de um transeunte ao avistar agentes do Estado. A sumissão a revista não se deu de modo aleatório, mas em fundada suspeita de ilegalidade já que os réus empreenderam fuga ao ver a presença da viatura.

Nesse mesmo sentido:

Preliminar – Ilegalidade da busca pessoal e ilegitimidade da Guarda Municipal para efetuar a prisão em flagrante delito dos acusados – Descabimento – Ausência de qualquer vício – Caráter permanente do crime – Permissivo do art. 301 do Código de Processo Penal – Apelação Criminal – Precedentes – Prefacial rejeitada. Recurso defensivo – Tráfico de Drogas – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei nº 11.343/06 – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida. Dosimetria – Pena-base acima do mínimo legal – Redução – Atos infracionais que não permitem o agravamento da pena – Inteligência da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça – Rigor excessivo afastado – Recurso parcialmente provido para este fim. Pleito de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 – Impossibilidade – Natureza e diversidade de drogas e circunstâncias do caso concreto que evidenciam a dedicação à atividade criminosa – Desprovemento. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Pleito não provido. Regime menos gravoso – Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502315-40.2021.8.26.0567; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Sentença procedente. Recurso ministerial. Pleito de condenação pela associação para o tráfico de drogas. Recursos defensivos. Preliminares: 1.1. Inépcia da denúncia. 1.2. Ilícitude probatória: a) ilicitude da busca pessoal; b) realização de atividade investigativa pela Polícia Militar; c) violação ao direito à intimidade em razão da devassa do aparelho celular. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Pedidos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; c) fixação do regime inicial aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Preliminares. 1.1. Inépcia da denúncia. Não acolhimento. Denúncia suficientemente detalhada com descrição pormenorizada das condutas atribuídas aos réus. Indicação do objeto material do tráfico e das circunstâncias de tempo e local da ocorrência delituosa. 1.2. Ilícitude probatória. 1.2.3. Ilícitude da busca pessoal. Configuração de fundadas razões para realização do procedimento de busca pessoal. Precedentes. Ação dos policiais militares realizada em contexto de flagrante delito durante regular atividade de policiamento ostensivo. Ilegalidade não reconhecida. 1.2.2. Investigação realizada pela Polícia Militar. Inocorrência. O art. 144 da Constituição Federal disciplina as atribuições dos órgãos de segurança pública determinando que à Polícia Militar cabe o desempenho de atividades próprias da polícia ostensiva, bem como a preservação da ordem pública. As atribuições constitucionais da Polícia Militar diferem-se daquelas estabelecidas aos órgãos de segurança pública responsáveis pelo exercício de atividades típicas de Polícia Judiciária – auxílio ao Poder Judiciário no cumprimento de suas ordens – e de Polícia Investigativa – relacionadas à colheita de provas da infração penal. Hipótese em que a prisão em flagrante não decorreu de procedimento de investigação, mas sim em razão do exercício da função ostensiva da Polícia Militar. 1.2.3. Violação do direito à intimidade e inviolabilidade das comunicações e do sigilo dos dados de conteúdo. 1.2.3.1. É corolário do direito fundamental da privacidade e da intimidade o resguardo da inviolabilidade das comunicações e de seus dados. A ordem constitucional assegurou tais espaços de liberdade conforme conhecida e consagrada fórmula dada pelo artigo 5º, XII. Assim,

o sigilo da comunicação, nada mais é do que a faculdade que toda pessoa tem de restringir o acesso de terceiros ao conteúdo de seus atos comunicativos. A interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas exige, portanto, prévia ordem fundada nos juízos de necessidade de urgência, vinculados para fins persecutórios. Os dados de comunicação, vale dizer, aqueles que indiquem a frequência das comunicações e os seus destinatários, por traduzirem um padrão, um hábito do interlocutor, também estão acobertados pelo sigilo, exigindo-se, igualmente, prévia ordem judicial. 1.2.3.2. A discussão sobre o acesso a dados registrados em aparelhos móveis não é nova. Em 2012, por ocasião do julgamento do HC nº 91.867/PA, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o questionamento sobre a licitude do manuseio de aparelho celular, com o consequente levantamento de dados de ligações registradas em contexto de prisão em flagrante. 1.2.3.3. Os significativos avanços tecnológicos alteraram, substancialmente, o perfil dos aparelhos de telefonia móvel o que impede uma transposição automática dos fundamentos do precedente. Recentes decisões do STJ. 1.2.3.4. O direito à intimidade e ao sigilo dos dados registrados no aparelho celular, no entanto, não são absolutos. Poderão ser mitigados ante a configuração de quadro de urgência a demonstrar o prejuízo à investigação criminal ou à segurança pública pela demora na obtenção do mandado judicial. Precedentes. 1.2.3.5. Configuração de situação de urgência no caso posto a julgamento a permitir a devassa do aparelho celular dos acusados sem autorização judicial. Necessidade de resguardo da investigação criminal e da segurança pública. 2. Do delito de tráfico de drogas. – ré Michele. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que realizaram operação para combate de tráfico de drogas no local dos fatos. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Alegação da ré Michele de desconhecimento quanto ao conteúdo do veículo que conduzia. Versão fantasiosa que não se sustenta. Apreensão de vultosa quantidade de entorpecente que não poderia passar despercebida. 3. Da absolvição dos apelantes Victor, Michel e Luidy por insuficiência probatória. Indícios de participação nos fatos que não são suficientes para lastrear o édito condenatório. Insuficiência de elementos a comprovar o vínculo entre os réus e a corré Michele. Termos da denúncia apócrifa que não foram corroborados por qualquer outro elemento produzido sob o crivo do contraditório. Perícia que restou prejudicada ante a impossibilidade de desbloqueio dos aparelhos celulares. 4. Do delito de associação para o tráfico. Absolvição dos réus Victor, Michel e Luidy pelo tráfico fragiliza a tese de existência de vínculo associativo entre acusados. Inexistência de provas da permanência e estabilidade. 5. Dosimetria que não merece reparo. 5.1. Quantidade exacerbada de drogas – 83 tijolos de maconha com aproximadamente 50kg. Aumento proporcional da pena base. 5.2. Vultosa quantidade de entorpecente que indica o envolvimento habitual da ré em atividades criminosas. Impossibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes. 5.3. Fixação correta do regime inicial fechado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva e direitos. 6. Recurso do Ministério Público e da ré Michele desprovidos. Recursos dos réus Victor, Michel e Luidy providos. Determinada a expedição de alvará de soltura em favor de Victor, Michel e Luidy. Prisão cautelar de Michele mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1500376-87.2021.8.26.0320; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 27/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA (ARTIGO 33, CAPUT, C/C §4º, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL – Afastada. Não há nulidade em busca pessoal quando a diligência policial veio amparada em fundadas razões, devidamente justificada. Inteligência dos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecente, de se manter a condenação da apelante decretada em primeiro grau. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 – Impossibilidade. Descabida a desclassificação para uso, quando a prova

dos autos demonstra de forma indubitosa a autoria e a materialidade delitiva do tráfico de drogas. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Promessa de vantagem a policiais para que se omitissem a praticar ato de ofício comprovada pela prova produzida nos autos. Dolo configurado. Condenação mantida. Afastada a preliminar, recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1506597-71.2021.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022)

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Incompetência da Guarda Municipal para efetuar a prisão em flagrante. Inocorrência. Realização de busca pessoal. Caracterização de fundada suspeita. Circunstâncias fáticas suficientes para amparar a medida. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus commissi delicti' e 'periculum libertatis'. Quantidade não ínfima e variada de drogas. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2135060-42.2022.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022)

Destaco que o precedente jurisprudencial apresentado pelo defensor junto ao STJ não possui caráter vinculante e, além disso, destaca-se no caso a fuga realizada pelos réus antes da abordagem, o que legitima e justifica toda a ação dos guardas municipais.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo: auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 138/140), auto de exibição (fl. 07), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

A autoria é certa.

Quando ouvidos perante a autoridade policial, ambos os réus exerceram o seu direito ao silêncio (fls. 15 e 14).

Em juízo, o réu Eduardo Felipe Almeida Santos Silva disse que os fatos são falsos. Disse que no dia dos fatos, estava com Fábio fumando baseado. Uma viatura da guará municipal apareceu com um guarda apenas e realizou revistas. O que chegou primeiro foi Márcio. O que chegou com a bolsa era o Márcio, sendo uma mochila preta. Não viu o que tinha dentro da mochila. Os dois estavam fumando baseado juntos. Foi até a casa de Fábio, o chamou, ele saiu e foram fumar baseado juntos. Conhece Fábio há muito tempo e são amigos desde a infância. Fábio trabalha como entregador. Trabalhava com seu cunhado em corte de árvores. Não é casado e sua namorada está grávida. Reside da estrada da Boiada 370.

O réu Fábio Eduardo Barbosa Mourão, por sua vez, em juízo, disse que os fatos são falsos. Disse que estava com Eduardo fumando maconha do outro lado da rua. Em dado momento apareceu uma viatura da GCM que os abordou com um guarda só. Após cerca de 30 minutos apareceu outro guarda, sendo este o Marcelo, descendo do morro com uma mochila preta dessas de colocar nas costas. Depois, a mochila foi aberta e havia maconha crack e cocaína. Não conhecia os guardas que fizeram sua prisão. Conhece Eduardo do bairro há cerca de quatro meses. Não sabe de nenhum envolvimento com o tráfico. Estava sentado no meio-fio e Eduardo chegou convidando para usar maconha. Eduardo estava com a maconha que fumaram. Quando tem maconha também convida Eduardo. Trabalha como entregador na lanchonete durante o dia e a noite na pizzaria de seu tio. É casado e tem um filho de um ano e oito meses. Os guardas fizeram revista pessoal no réu. Estava fumando maconha em frente a sua casa, mas não se lembra de haver outras pessoas no local.

A versão dos réus não guarda amparo na prova dos autos.

Luciano da Silva Prado disse que é guarda municipal. Na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina, sendo que receberam denúncias de tráfico de drogas que estaria ocorrendo no local. Quando chegaram no local, os dois suspeitos empreenderam fuga pela mata após avistarem a viatura. Imediatamente, deu-se início a perseguição aos indivíduos que, posteriormente, foram capturados. Ambos os

suspeitos portavam sacolas plásticas e em seu interior foram encontradas as drogas descritas no boletim de ocorrências. O local é uma vila com diversas empresas. É comum que a guarda faça patrulhamentos na região para coibir crimes, quando é possível. No dia dos fatos, havia recebido denúncia via rádio de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local. Pelos réus terem saído correndo ao ver a viatura suspeitaram que estivesse ocorrendo algo de ilícito. Os réus saíram correndo ao ver a viatura. Tem um bar nas proximidades. Na calçada havia outras pessoas. Não conhecia os acusados antes desses fatos.

Marcio Alexandre da Silva disse que é guarda municipal de Franco da Rocha. Disse que receberam denúncia via central de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no endereço indicado em inicial. Ao chegar o local, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita pois, após avistarem a presença da viatura, empreenderam fuga a pé o que motivou a abordagem. Ambos os suspeitos portavam em suas mãos uma sacola plástica. Foi feita a abordagem e em poder dos réus foram apreendidas as sacolas e localizaram no interior destas entorpecentes que constam do boletim de ocorrências. Não tentou contato com a polícia militar para que fossem ao local. Desde o recebimento da denúncia via rádio até o encontro dos réus passou-se cerca de 20 minutos. No local há algumas empresas e uma mata. É corriqueiro realizar rondas no local, por haver informações de ser local de ponto de tráfico de drogas, o que é feito a mando do comandante para coibir crimes. Há um bar nas proximidades, mas não sabe se ele estava vazio. Não se recorda qual a cor da sacola, mas lembra-se que eram plásticas. Não conhecia os réus antes desses fatos.

Quanto aos guardas civis, não há indícios de que tinham motivos para acusar os réus de forma leviana e gratuitamente, até porque sequer os conheciam.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273). "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respaldar danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo." (TACrim, 12ª Câmara, rel. Desembargador João Morenghi, Apelação 1473255/5).

Como se vê, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação dos acusados pelo delito de tráfico de drogas. Observo que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana. A quantidade de droga apreendida, sua natureza, forma de acondicionamento e os depoimentos prestados pelos guardas ouvidos, levam à certeza de que os acusados guardavam drogas na ocasião, impondo-se, pois, a sua condenação.

Ainda, destaco que os relatos apresentados pelos réus estiveram com claras contradições, sendo certo que, a despeito de terem tentado combinar suas versões não o fizeram de modo eficiente. Como se vê, indicaram de modo contraditório qual dos guardas estaria de posse da suposta mochila. Ainda, Eduardo disse que chamou Fábio que estava em sua casa. Este, no entanto, disse que estava sentado na rua do lado de frente à sua casa, revelando, portanto, que suas versões não se coadunam. Dessa forma, cabe assinalar que a denúncia imputa aos réus a conduta de "ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente", e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução.

Passo a dosar a pena em relação ao réu Fábio Eduardo Barbosa Mourão

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, verifico que o

réu não possui maus antecedentes (fls. 114/115 – em que pese o réu estar sendo processado por crimes praticados antes do delito aqui julgado, os feitos ainda não foram julgados). As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Portanto, fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. O réu não possui maus antecedentes, ainda que responda a outro processo do mesmo crime. No entanto, nos autos há comprovação de que estaria trabalhando na época dos fatos. Assim, aplico ao réu a causa de diminuição de pena do §4º do art. 44. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias multa) .

Nos termos dos artigos 49, §1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, fixo o regime aberto como o inicial ao cumprimento da pena ora aplicada.

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a saber: pagamento de prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos em prol de entidade assistencial a ser designada pelo juízo da execução penal; prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação em prol de entidade assistencial a ser designada pelo juízo da execução penal.

Passo a dosar a pena em relação ao réu Eduardo Felipe Almeida Santos Silva. Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal, verifico que o réu não possui maus antecedentes. As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Portanto, fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência (0000161-32.2018.8.26.0502/0001764-82.2016.8.26.0544 – fl. 117), razão pela qual elevo a pena em 1/6, perfazendo a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no mínimo legal.

Entendo a inaplicável a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando-se que o réu é reincidente.

Nos termos dos artigos 49, §1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado como o inicial ao cumprimento da pena ora aplicada, uma vez que o réu é reincidente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno: Fabio Eduardo Barbosa Mourão e Eduardo Felipe Almeida Santos como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de

A) Fabio Eduardo Barbosa Mourão: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias multa), no mínimo legal. Substituída a pena de prisão por duas restritivas de direito, a saber: 1. pagamento de prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos em prol de entidade assistencial a ser designada pelo juízo da execução penal; 2. prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação em prol de entidade assistencial a ser designada pelo juízo da execução penal.

B) Eduardo Felipe Almeida: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no mínimo legal.

Tendo respondido ao processo preso, o réu Eduardo não poderá recorrer em liberdade, eis que subsistem os motivos que ensejaram sua prisão, em especial após a prolação de sentença condenatória a pena de mais de cinco anos de reclusão. O acusado Fábio Eduardo poderá recorrer em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura clausulado.



Decreto, portanto, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções. A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença. Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Custas na forma da lei. Defiro aos acusados a gratuidade de justiça haja vista as condições financeiras dos acusados indicados em interrogatório.

P. I. C.

Franco da Rocha, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA